

1501742-73.2021.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... para a apuração da prática de tráfico de entorpecentes.

Presente as condições e não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisado, passo à análise do mérito.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada aos réus encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501742-73.2021.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501742-73.2021.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2184309/2021 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 18932549 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 1216/21/414 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2184309 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 1216/21/414 - 01º D.P. CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO AFONSO DA MOTA PINTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de PEDRO AFONSO DA MOTA PINTO e IVANILDA DE ARAÚJO MACHADO, já devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art.

33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal. Segundo consta na denúncia (fls. 113-116), no dia 07 de julho de 2021, por volta das 19:45 horas, na Rua Júlio de Souza Galvão, altura do nº 1.255, em via pública, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca, PEDRO e IVANILDA, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de propósitos e divisão de tarefas, um aderindo à conduta do outro, mantinham em depósito e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 1 porção de "maconha" ("Cannabis Sativa L") com massa bruta de 21,11 gramas; 15 pinos "cocaína" com massa bruta total de 10,35 gramas; e 199 porções de "crack" (cocaína), individualmente embaladas em plástico, com massa bruta total de 22,64 gramas, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com o Ministério Público, policiais militares receberam informações de que um homem e uma mulher estariam comercializando substâncias entorpecentes no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, indicando também onde as drogas estariam ocultas. Chegando lá, os agentes públicos surpreenderam IVANILDA em pé, próximo à janela de um carro, o qual deixou apressadamente o local ao notar presença policial, enquanto PEDRO estava sentado ao lado de uma fogueira. Realizada a revista pessoal, os policiais encontraram R\$ 20,00 em espécie em poder de IVANILDA e R\$ 9,40 em poder de PEDRO. Nas imediações, embaixo de um pedaço de madeira, os agentes públicos encontraram uma lata de "Nescau" contendo 199 pedras de crack embaladas em saco plástico tipo sacolé, 15 pinos de cocaína e um pequeno tijolinho de maconha, tudo pronto para a venda, de modo que deram voz de prisão ao casal.

Diante da apreensão dos entorpecentes PEDRO confessou a traficância aos policiais, mantendo tal versão durante seu interrogatório, ocasião em que afirmou ter começado a traficar pelo fato de estar desempregado, tentando isentar IVANILDA de culpa (fl. 07). IVANILDA negou a prática delitiva, prestando justificativas desconstruídas para sua conduta e presença em conhecido ponto de venda de drogas (fl. 06).

As informações pretéritas, a natureza da droga, sua diversidade e forma de acondicionamento e tudo mais quanto consta dos autos demonstram, na visão do Ministério Público, que os réus de comum acordo, promoviam o narcotráfico no local dos fatos.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 117-119, seguindo-se a regular citação dos réus (fls. 136 e 137), com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 131-134 e 139-140).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da denúncia, com a absolvição de IVANILDA e a condenação de PEDRO nos termos da denúncia. A Defesa de PEDRO requereu o reconhecimento da confissão e a fixação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime aberto. A Defesa de IVANILDA acompanhou a manifestação do Ministério Público e requereu a improcedência da demanda.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação instaurada para a apuração da prática de tráfico de entorpecentes. Presente as condições e não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisados, passo à análise do mérito.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada aos réus encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09-12), auto de exibição e apreensão (fl. 13), laudo de constatação preliminar (fls.

14-15), laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo positivo para maconha e cocaína (fls. 97-108) e pela prova oral colhida em juízo. Em relação à autoria, de se considerar que os réus foram presos em flagrante delito.

Na fase policial, PEDRO, disse que: quanto aos fatos em apuração confessa que as drogas apreendidas por policiais militares na noite da ocorrência, no local dos fatos, realmente lhe pertencem e se destinavam a venda; está desempregado e, sem outra forma de renda, resolveu vender drogas, mas acabou preso; afirma que a testemunha IVANILDA não tem nenhuma relação com as drogas apreendidas; se reservou no direito de somente prestar outros esclarecimentos sobre os fatos em juízo; já foi preso por tentativa de latrocínio, mas foi absolvido; está arrependido da sua conduta. (fl. 07)

Interrogado em juízo, disse que: confessa que estava traficando, porém IVANILDA não estava junto; IVANILDA estava no local, mas apenas o depoente estava traficando; na época namorava uma moça que estava por perto, a quem entregou o celular no momento da abordagem; estava traficando há 3 dias no local; estava desempregado, ofereceram ao depoente as drogas e aceitou; ainda tem dívida com o tráfico pois não havia pago pelas drogas que foram apreendidas.

A seu turno, IVANILDA, na fase policial, que disse: na noite do ocorrido, foi abordada por policiais militares na companhia do autuado; nega que tivesse exercendo o tráfico de drogas em conjunto com ele; afirma que a família do seu namorado mora nos arredores do local dos fatos e, como ele foi preso na semana passada, na data de em questão esteve lá para conversar com uma tia dele sobre a possibilidade da soltura dele nos próximos dias, razão pela qual esperava por ela nas proximidades da fogueira onde o autuado estava, "esquentando o fogo né..."; presenciou a abordagem policial e viu quando o autuado confessou aos policiais que as drogas apreendidas lhe pertenciam; conhece o autuado, mas não tem amizade com; somente se encontrava pelo local a espera da tia do seu namorado; não realiza o tráfico de drogas e não é verdade que, ao ser abordada pelos policiais militares, estava entregando algo para o motorista de um carro; "eu só tava esquentando fogo junto com ele (autuado) e a namorada dele mesmo..."; quanto ao dinheiro encontrado em seu poder afirma que recebeu da mãe do seu namorado e lhe pertencia; não tem outras informações sobre os fatos investigados.

Interrogada em juízo disse que: nega os fatos; estavam em 4 pessoas no local; estava sentada conversando; em frente da rua mora a tia do marido da depoente; estava esperando a tia do marido; os policiais chegaram e encontraram as drogas e disseram que ela estava junto; Ailton é o esposo da depoente; ele estava preso e a depoente estava esperando para irem buscá-lo; a tia de Ailton se chama Maria; o marido da depoente foi preso de novo; já viu PEDRO algumas vezes pois ele mora perto da mãe da depoente; no dia dos fatos estava conversando com a Raquel, que estava ficando com PEDRO e com a outra moça; estava sentada e não foi falar com qualquer pessoa em um veículo.

A testemunha, Mario Juliano De Oliveira Takeshita, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: é policial militar nesta cidade; na noite dos fatos, estava de serviço em companhia do colega de farda Matos; receberam a solicitação do COPOM para se dirigissem ao local dos fatos onde um homem e uma mulher que se encontravam no entorno de uma fogueira estariam comercializando drogas; deslocaram-se ao local indicado; chegando lá, ao contornarem a esquina, avistaram um carro parado e a testemunha IVANILDA na porta e o autuado próximo da fogueira; ao se aproximarem, o referido veículo se evadiu sem que pudessem abordá-lo ou identificá-lo; procederam a abordagem e revista pessoal no casal e somente encontraram em poder de IVANILDA R\$ 20,00 em dinheiro e na posse do autuado localizaram R\$ 9,40 também em dinheiro; a informação recebida já noticiava que a droga comercializada estaria escondida no chão nas proximidades do local onde o autuado se encontrava e, por isso, fizeram uma busca rápida; de fato, sob uma pequena tábua encontraram um lata de "Nescau" e no seu interior havia 199 pedras de "crack" embaladas em saco plástico tipo sacolé, além de 15 pinos de cocaína e um pequeno tijolinho de maconha de cerca de 20 gramas embalada em plástico filme, tudo pronto para a venda; ao serem questionados sobre a propriedade da droga, o autuado confessou que lhes pertenciam e isentou IVANILDA de

responsabilidade; já a testemunha IVANILDA negou que estivesse traficando, alegando que ali se encontrava na espera do namorado que havia sido preso dias antes também por tráfico naquele mesmo local; deram voz de prisão ao autuado e o apresentaram na Delegacia para as providências cabíveis; já conhecia o autuado anteriormente porque ele tem outras passagens policiais e testemunha IVANILDA, embora não tenham conseguido outras provas do envolvimento na data de hoje, também é suspeita da prática do crime de tráfico, inclusive informa que ela foi abordada junto com o namorado dela na semana passada no mesmo local e ele acabou preso por tráfico de drogas; nenhum dos envolvidos portavam celular ou qualquer outro produto de procedência ilícita. (fl. 07).

Em juízo relatou que: no local dos fatos já estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes; naquele dia receberam informações de que havia um casal próximo a uma fogueira traficando; foram ao local e quando os avistaram, IVANILDA estava debruçada na janela do veículo como se estivesse entregando algo; o carro saiu e com IVANILDA encontraram 20 reais e com pedro pouco mais de 9 reais; a denúncia indicava o local em que estavam as drogas e em revista pelo local encontraram as drogas em uma latinha; PEDRO admitiu que estava traficando e que era dele o entorpecente; a ré era envolvida com uma rapaz chamado Leandro que era traficante; uma semana antes, IVANILDA tinha sido pega com o namorado que foi preso; não se recorda se PEDRO disse que ela estava junto; no local estava o PEDRO, a namorada e outras pessoas que estavam circulando por ali, além de umas crianças; a denúncia dizia que as drogas estavam próximas da fogueira e da cerca.

A testemunha, Paulo Rafael De Matos, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: é policial militar nesta cidade; na noite dos fatos, estava de serviço em companhia do colega de farda Takeshita; receberam a solicitação do COPOM para se dirigissem ao local dos fatos onde um homem e uma mulher que se encontravam no entorno de uma fogueira estariam comercializando drogas; deslocaram-se ao local indicado; chegando lá, ao contornarem a esquina, avistaram um carro parado e a testemunha IVANILDA na porta e o autuado próximo da fogueira; ao se aproximarem, o referido veículo se evadiu sem que pudessem abordá-lo ou identificá-lo; procederam a abordagem e revista pessoal no casal e somente encontraram em poder de IVANILDA R\$ 20,00 em dinheiro e na posse do autuado localizaram R\$ 9,40 também em dinheiro; a informação recebida já noticiava que a droga comercializada estaria escondida no chão nas proximidades do local onde o autuado se encontrava e, por isso, fizeram uma busca rápida; de fato, sob uma pequena tábua encontraram um lata de "Nescau" e no seu interior havia 199 pedras de "crack" embaladas em saco plástico tipo sacolé, além de 15 pinos de cocaína e um pequeno tijolinho de maconha de cerca de 20 gramas embalada em plástico filme, tudo pronto para a venda; ao serem questionados sobre a propriedade da droga, o autuado confessou que lhes pertenciam e isentou IVANILDA de responsabilidade; já a testemunha IVANILDA negou que estivesse traficando, alegando que ali se encontrava na espera do namorado que havia sido preso dias antes também por tráfico naquele mesmo local; deram voz de prisão ao autuado e o apresentaram na Delegacia para as providências cabíveis; já conhecia o autuado anteriormente porque ele tem outras passagens policiais e testemunha IVANILDA, embora não tenham conseguido outras provas do envolvimento na data de hoje, também é suspeita da prática do crime de tráfico, inclusive informa que ela foi abordada junto com o namorado dela na semana passada no mesmo local e ele acabou preso por tráfico de drogas; nenhum dos envolvidos portavam celular ou qualquer outro produto de procedência ilícita. (fl. 08).

Em juízo relatou que: receberam a denúncia via COPOM dando conta de um casal traficando; ao adentrarem a rua viram IVANILDA próxima a um veículo, que entregou algo e recebeu algo; o veículo saiu e não possível abordá-lo; encontraram 20 reais com IVANILDA e pouco mais de 9 reais com PEDRO; a denúncia dizia que a droga estava próxima deles; foram até uma cerca e encontraram embaixo de uma tábua uma lata de nescau com as drogas; PEDRO admitiu que estava traficando e a droga era dele; no local estavam PEDRO, IVANILDA, algumas crianças; do outro lado da rua, na calçada tinha algumas pessoas; a denúncia não dava as características, apenas indicava que era um casal; IVANILDA foi conduzida uma semana antes com o namorado por tráfico de drogas; o namorado dela ficou preso;

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que PEDRO confessou que as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinavam a comercialização, entretanto afastou a possibilidade de IVANILDA ser sua comparsa. reconheceu que ela se encontrava no local, porém negou que estivessem atuando em conjunto. Essa versão foi apresentada nas duas oportunidades em que ele foi ouvido.

IVANILDA, tanto na esfera policial quanto em juízo negou as acusações e disse que, apesar de estar no local no momento, não tem qualquer envolvimento com PEDRO.

Ambos disseram que havia outras pessoas por lá, inclusive uma namorada/ficante de PEDRO.

Os policiais afirmaram terem visto IVANILDA entregando algo para alguém em um veículo que saiu antes que pudessem alcançar o local. E essa é única circunstância que a vincularia às drogas, já que com ela nenhum entorpecente foi encontrado e PEDRO nega firmemente sua participação.

Nessas condições, não há provas suficientes de que IVANILDA concorreu para a infração penal, ao passo que quanto a PEDRO, sua confissão, a apreensão das drogas e os depoimentos dos policiais são suficientes para sua responsabilização.

Os réu, de forma consciente e espontânea, praticavam a guarda e a venda das drogas, consistentes em 1 porção de “maconha” (“Cannabis Sativa L”) com massa bruta de 21,11 gramas; 15 pinos “cocaína” com massa bruta total de 10,35 gramas; e 199 porções de “crack” (cocaína), individualmente embaladas em plástico, com massa bruta total de 22,64 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com isso, resta preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da

antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação dos réus PEDRO AFONSO DA MOTA PINTO nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal. Adoto, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; constam antecedentes (fls. 170, autos nº. 1500194-81.2019, da 1ª Vara de Capão Bonito, com trânsito em julgado em 14/09/2021, mas data do fato em 18/12/2018). Não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como circunstâncias; as consequências são inerentes ao tipo penal; por fim, o comportamento da vítima em nada facilitou para o cometimento da infração.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida maconha, cocaína e crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Capão Bonito.

Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”.

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim,

considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidos, uma porção de "maconha" ("Cannabis Sativa L") com massa bruta de 21,11 gramas; 15 pinos "cocaína" com massa bruta total de 10,35 gramas; e 199 porções de "crack" (cocaína), individualmente embaladas em plástico, com massa bruta total de 22,64 gramas. O montante já se mostra suficiente para ensejar maior reprovação, de modo que a circunstância deve ser considerada negativa.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confirma-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceram-se duas circunstâncias como negativas (os antecedentes, a quantidade e a natureza da substância), acresço ao piso 3/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 8 anos de reclusão 800 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se

constar a atenuante da confissão prevista no art. 65 do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, convertendo a pena provisória em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão 729 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, ausente causa de aumento de pena. Em relação à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, embora o réu seja tecnicamente primário, conta com maus antecedentes e confessou estar desempregado, fazendo do tráfico seu meio de vida. Nessas circunstâncias, não é cabível a minorante. Assim, torno definitiva a pena 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão), e tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, natureza e quantidade de drogas - art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso, o réu foi condenado a pena superior a 4 anos e, portanto, não satisfaz o requisito objetivo para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I, do CP), nem para a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira dos réus.

2.2.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Recepção. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da

reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o réu PEDRO AFONSO DA MOTA PINTO, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29, "caput", do Código Penal, às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 dias-multa.

b) ABSOLVER a ré IVANILDA DE ARAÚJO MACHADO da acusação de prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29, "caput", do Código Penal.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA a prisão preventiva pois o réu é portador de maus antecedentes, foi preso com elevada quantidade de drogas, especialmente crack e confessou que estava desempregado e traficando há 3 dias, ou seja, fazia do comércio de entorpecentes seu meio de vida.

Recomende-se a manutenção da custódia cautelar/ expeça-se guia de recolhimento provisório.

4.2 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
 - b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
 - c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
 - d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e eventualmente ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
 - e) Ultrapassados prazos legais sem requerimento de restituição, autorizo desde já a destruição dos demais objetos apreendidos (fls.05/06);
 - f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA